



上海交通大学
凯原法学院

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY
KOGUAN LAW SCHOOL

互联网不正当竞争行为

内容提要

- 概述
- 流量劫持行为
- 违背用户意愿行为
- 恶意不兼容行为
- 其他行为

第13条

以前规定：技术手段；现在 数据和算法...

- 经营者利用网络从事生产经营活动，应当遵守本法的各项规定。经营者不得利用技术手段**数据和算法、技术、平台规则等**，通过影响用户选择或者其他方式，实施下列妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为：
 - 未经其他经营者同意，在其合法提供的网络产品或者服务中，插入链接、强制进行目标跳转；
 - 误导、欺骗、强迫用户修改、关闭、卸载其他经营者合法提供的网络产品或者服务；
 - 恶意对其他经营者合法提供的网络产品或者服务实施不兼容；
 - 其他妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为。

第13条

- 经营者不得以欺诈、胁迫、避开或者破坏技术管理措施等不正当方式，获取、使用其他经营者**合法持有的数据**，损害其他经营者的合法权益，扰乱市场竞争秩序。
- 经营者不得滥用平台规则，直接或者指使他人对其他经营者实施**虚假交易、虚假评价或者恶意退货**等行为，损害其他经营者的合法权益，扰乱市场竞争秩序。

黑灰产，专业刷单

第14条

- 平台经营者不得强制或者变相强制平台内经营者按照其定价规则，以低于成本的价格销售商品，扰乱市场竞争秩序。



第21条

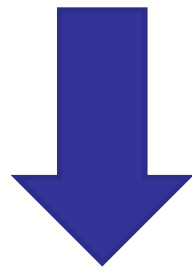
- 平台经营者应当在平台服务协议和交易规则中明确平台内公平竞争规则，**建立不正当竞争举报投诉和纠纷处置机制**，引导、规范平台内经营者依法公平竞争；发现平台内经营者实施不正当竞争行为的，应当及时依法**采取必要的处置措施**，保存有关记录，并按规定向平台经营者住所地**县级以上人民政府监督检查部门**报告。

为什么会有互联网专条？

- 在《反不正当竞争法》修订之前，互联网领域产生了大量的不正当竞争纠纷。
- 自**2002**年以来，网络不正当竞争纠纷呈逐年增长的态势，**2012**年后呈爆发趋势；**2015**年全年该院受理网络不正当竞争纠纷案**160** 件；**2016**年前5个月便已受理了**163** 件。而其中平均**80%**以上为新型不正当竞争案件。

为什么会有互联网专条？

- 这些新型的不正当竞争行为游离于《反不正当竞争法》所明确规定的具体行为类型之外，因此需要运用《反不正当竞争法》第2条一般条款予以规制。



- “向一般条款逃逸”的问题

互联网对反不正当竞争规制的影响

- 1. 竞争关系和竞争行为的新认识

- 流行跨界、行业界限模糊和淡化

- 2. 动态竞争的新考量

如果：损害可控+明显的社会效益，一般不会判定为不正当竞争

- 传统市场：存量稀缺资源（静态利益）
- 互联网：增量资源（整体竞争效果）

- 3. 创新需求的新认识

- 技术中立——诚信公平

- 4. 竞争损害的认定

造成浏览量的损失，可能构成不正当竞争

- 互联网经济的竞争主要是对注意力的争夺

内容提要

- 概述
- 流量劫持行为
- 违背用户意愿行为
- 恶意不兼容行为
- 其他行为

法律规定

- (一)未经其他经营者同意，在其合法提供的网络产品或者服务中，插入链接、强制进行目标跳转；
或的关系

较早的案例

- 奥商网络公司经营范围包括网络工程建设、网络技术应用服务、计算机软件设计开发等。该公司在其网站介绍其“网络直通车”业务时称：无需安装任何插件，广告网页强制出现。
- 介绍“搜索通”产品表现形式时，以图文方式列举了下列步骤：第一步在搜索引擎对话框中输入关键词；第二步优先出现网络直通车广告位（5秒钟展现）；第三步同时点击上面广告位直接进入宣传网站新窗口；第四步5秒后原窗口自动展示第一步请求的搜索结果。
- 最高人民法院指导案例45号：北京百度诉联通青岛、奥商案

1、竞争关系

- 2009年4月14日，百度公司发现通过青岛市网通接入互联网，登录百度页面并在对话框中输入“鹏飞航空”后，点击“百度一下”，会弹出显示有“打折机票抢先拿就打114”的页面，点击该页面会打开<http://air.qd.sd.cn>的页面。

虽然联通青岛公司是互联网接入服务经营者，百度公司是搜索服务经营者，服务类别上不完全相同，但是联通青岛公司实施的在百度搜索结果出现之前弹出广告的商业行为，与百度公司的付费搜索模式存在竞争关系。

2、行为的不正当性

- 联通青岛与奥商实施的行为，是利用了百度搜索引擎在我国互联网用户中被广泛使用优势，利用技术手段，让使用联通青岛提供互联网接入服务的网络用户，在登录百度网站进行关键词搜索时，在正常搜索结果显示前强行弹出奥商发布的与搜索的关键词及内容有紧密关系的广告页面。
- 这种行为诱使本可能通过百度搜索结果检索相应信息的网络用户点击该广告页面，影响了百度向网络用户提供付费搜索服务与推广服务，属于利用百度提供的搜索服务来为自己牟利。
- 该行为既没有征得百度同意，又违背了使用其互联网接入服务用户的意志，容易导致上网用户误以为弹出的广告页面系百度所为，会使上网用户对百度提供服务的评价降低，对百司的商业信誉产生不利影响，损害了百度的合法权益，同时也违背了诚实信用和公认的商业道德，已构成不正当竞争。

两个较新的案例

- 百度诉搜狗案
 - **(2015)京知民终字第2200号**
- 爱奇艺诉搜狗案
 - **(2018)沪73民终420号**

(1) 百度诉搜狗案

- 案由
 - 搜狗输入法提供的下拉提示词（输入候选）覆盖和隐藏了百度搜索引擎的下拉菜单（搜索候选）；
 - 引诱百度用户点击搜狗的输入候选，进入搜狗的搜索结果。
- 判决：
 - 搜狗败诉

(2) 爱奇艺诉搜狗案

- 案由：
 - 搜狗输入法在“输入首选”中融入了“搜过候选”的内容，与爱奇艺的“搜过候选”进行上下排列；
 - 引诱爱奇艺用户点击搜狗的输入候选，进入搜狗的搜索结果。
- 判决：
 - 爱奇艺败诉

行为定性

- 虽然法院没有明确，但应当是《反法》第12条
 - （一）未经其他经营者同意，在其合法提供的网络产品或者服务中，插入链接、强制进行目标跳转；
- 本质性问题：基层应用在其他应用中被使用时的行为合理性边界。

百度案的法院分析（1）

- 百度是否受到损失：
 - 搜狗公司因被诉搜狗输入法下拉菜单行为而获得的用户流量原本属于百度搜索引擎；
- 被控行为是否具有正当性
 - 应当考虑百度流量的流失是仅仅由被诉行为直接造成的，还是基于用户的主动选择的结果。

百度案的法院分析（2）

- 搜狗的行为易使用户误认为其使用的是百度下拉菜单服务，从而在不知情的情况下使用了搜狗搜索引擎；
- 用户注意力的争夺至少应建立在用户明确知晓的情况下，有意造成用户混淆的竞争行为通常属于违反公认商业道德的行为；
- 搜狗的下拉菜单（输入候选）并非不合理的商业模式，被诉行为的不正当性系源于该特定方式所产生的用户混淆。

爱奇艺案法院的分析（1）

- 爱奇艺公司的利益是否因搜狗公司的行为遭受了损失
 - 由于被控行为的介入，可能导致部分交易机会或搜索流量从爱奇艺公司转移至搜狗公司或其关联公司，**爱奇艺公司所遭受损失是客观的。**
- 被控行为对爱奇艺公司经营的影响
 - 爱奇艺公司由此所遭受的**损失是有限的**
 - 爱奇艺网站的正常运营并**没有受到实质性的妨碍或破坏**

爱奇艺案法院的分析（2）

- 被控行为对消费者权益保护的影响
 - 其提供了更多的搜索结果供用户选择，整体上**消费者的福利有所提高**；也没有造成消费者的混淆。
- 被控行为对市场竞争秩序的影响
 - 互联网平台以各种方式进入竞争对手领域参与竞争是不可避免的
 - 本案被控行为并未**过度妨碍爱奇艺网站的正常运营**，也未破坏正常的市场选择功能，尚未达到扰乱市场竞争秩序的程度。

流量劫持——插入链接、强制跳转

- 是否在他人合法产品或服务中插入链接、实施强制跳转的行为皆构成不正当竞争？
- 淘宝开发一键向微信发放红包和商品链接的功能
发放链接是用户的行为 不构成不正当竞争
- 微信予以屏蔽
可以制造一些障碍，但是不能损坏消费者的福利，故可以屏蔽链接，但是不能屏蔽所有的口令
- 淘宝通过口令规避

是否推动合理竞争
对消费者利益的考量

内容提要

- 概述
- 流量劫持行为
- 违背用户意愿行为
- 恶意不兼容行为

法律规定

- (二)误导、欺骗、强迫用户修改、关闭、卸载其他经营者合法提供的网络产品或者服务；
 - 该项争议最少的。
 - 只是，合法产品不等于合适的产品，为保证自己产品或者服务的品质而拒绝不符合系统基本要求在互联网平台也是常见的。
 - 如果有合理理由，用技术手段限制第三方合法产品或者服务并不失正当性。

百度在线诉北京3721

- 被告的“**3721网络实名**”软件与原告的“**百度IE搜索伴侣**”软件均是搜索服务软件。原告认为被告“**3721网络实名**”软件在用户安装“**百度IE搜索伴侣**”软件时会不断弹出软件冲突提示和警告，该行为影响和干扰了百度软件的下载、安装与运行。
- 北京市第二中级人民法院(2004)二中民终字第02387号

1、著作权问题

- 第一，在**2002年7月**，存在无论先安装哪个涉案软件，均出现在后安装者修改在先安装者注册表信息的情况，致使在先安装的软件不能正常运行。
 - 但注册表信息并非计算机软件作品的组成部分，对注册表信息的修改不应视为对软件作品的修改。

2、不正当竞争问题

- 在2003年10月17日，在先安装“3721网络实名”软件后，系统目录中出现cnsminp文件。再登陆百度网站，则无法通过点击鼠标左键的通常方式下载“百度IE搜索伴侣”软件，仅可通过点击鼠标右键以另存为方式下载，但无法安装。
- 在2004年2月17日，安装“3721网络实名”软件后，下载安装“百度IE搜索伴侣”软件时，安装失败并弹出“软件冲突警告”对话框，选择其中每一选项后，安装均失败。而卸载“3721网络实名”软件后不受影响。
 - 三七二一公司的上述行为不仅使用户不能正常行使其选择权，而且使百度公司的“百度IE搜索伴侣”软件不能接受用户的平等选择，从而丧失了相应的交易机会。

QQ与360不正当竞争纠纷

- 奇虎公司等为达到其商业目的，诱导并提供工具积极帮助用户改变QQ软件的运行方式，并同时引导用户安装360安全卫士，替换QQ软件安全中心，破坏了QQ软件相关服务的安全性并对QQ软件整体具有很强的威胁性，减少了腾讯公司经济收益和增值服务交易机会，违反了诚实信用原则和公认的商业道德。奇虎公司等无事实依据地宣称QQ软件会对用户电脑硬盘隐私文件强制性查看，并且以自己的标准对QQ软件进行评判并宣称QQ存在严重的安全问题，造成了用户对QQ软件及其服务的恐慌及负面评价，该评论已超出正当商业评价、评论的范畴，突破了法律界限。奇虎公司等经营扣扣保镖时，将自己的产品和服务嵌入QQ软件界面，取代了QQ软件的部分功能，其根本目的在于依附QQ软件强大用户群，通过对QQ软件及其服务进行贬损的手段来推销、推广360安全卫士，从而增加自己市场交易机会并获取市场竞争优势，此行为本质上属于不正当地利用他人市场成果，为自己谋取商业机会从而获取竞争优势的行为。违反了诚实信用和公平竞争原则，构成不正当竞争。

课堂案例

- 360阻碍搜狗自动成为默认浏览器的设置合法吗？
不构成，提升消费者福利：用户往往不希望随意改变默认浏览器；
- 用威胁性的语言让消费者放弃呢？
构成不正当竞争

对搜索结果加标，“可能含有木马病毒”
小概率事件+大规模加标

应当确保干扰的合理性与必要性

我国法律原则：非公益不干扰

内容提要

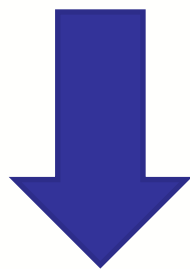
- 概述
- 流量劫持行为
- 违背用户意愿行为
- 恶意不兼容行为
- 其他行为

法律规定

- (三)恶意对其他经营者合法提供的网络产品或者服务实施不兼容;

一、如何理解“恶意”？

- 如果认为只有恶意的不兼容行为属于妨碍、破坏行为，而非恶意的不兼容行为不属于不正当竞争，那么“恶意”的判断标准如何把握？



- “恶意”是否意味着“故意”？

兼容或不兼容是正常市场现象
ios与安卓不兼容
是否符合诚实信用和商业惯例

二、如何判断

- 是否由正当事由？
- 金山网络公司诉合一公司不正当竞争纠纷案
- 合一公司的行为属于“防御”还是“恶意为之”
- 法院认定：优酷网对猎豹浏览器提示不兼容情况，是因猎豹浏览器多次未经合一公司的许可前提下，对优酷网内容及服务进行篡改所致，但前述事件均发生在合一公司在另案中提出金山网络公司通过猎豹浏览器过滤优酷网视频广告等行为的相同时间段，因此合一公司对金山网络公司在实施不正当竞争行为当时以不兼容措施进行防御并无不妥。此外，本案证据显示，在金山网络公司通过猎豹浏览器过滤优酷网视频广告行为停止的情况下，合一公司未持续对猎豹浏览器的不兼容行为。 防御行为，正当事由，不构成不正当竞争

二、如何判断

- 是否超出必要限度？
- 360诉QQ案
- 腾讯公司和腾讯计算机公司采取“二选一”的目的不是要拒绝与用户交易，而在于逼迫用户只能与其进行交易而不与360进行交易。上述该行为实质上仍然属于限制交易的行为。
- 在法有明文规定的情况下，腾讯公司和腾讯计算机公司没有依法行使诉讼权利寻求制止不法侵害行为的途径，转而单方面采取“二选一”的行为，致使“3Q大战”范围扩大波及用户，其行为缺乏正当性。另外，腾讯公司和腾讯计算机公司强迫用户采取“二选一”的行为也超出了必要的限度。

内容提要

- 概述
- 流量劫持行为
- 违背用户意愿行为
- 恶意不兼容行
- 其他行为

法律规定

- 第（四）项禁止“其他妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为”
- 很多实例都可以证明这一项难以施行，比如所有软件运行都需要占用内存，而占用内存无疑会导致其他软件运行缓慢。

该款没有构成要件，应参照一般条款来进行适用

百度诉奇虎爬虫协议案

- 爬虫协议，又称**Robots** 协议，是指互联网网站所有者使用**Robots.txt**文件，向搜索引擎的网络机器人给出是否可以抓取网站内容的指令。
- 原告百度公司诉称被告奇虎公司在其已经设置**Robots**协议的情况下，无视原告的**Robots**协议，擅自抓取、复制百度网站页面并生成网页快照复制件存储于被告服务器中。本案争议的焦点在于被告奇虎司未遵守爬虫协议的行为是否构成不正当竞争
- （2013）中民初字第2668号

“协商—通知”分为四个步骤：

- 第一，搜索引擎服务商在认为网站爬虫协议设置不合理时，应当向网站服务商或所有者提出**书面**修改爬虫协议、准许其爬虫机器人抓取的请求；
- 第二，网站服务商或所有者在知晓该请求后，如不同意修改，应当在合理的期限内，**书面**、明确的提出其拒绝修改**Robots**协议的合理理由告知搜索引擎服务商；

“协商—通知”分为四个步骤：

- 第三，搜索引擎服务商认为理由不成立的，双方可以向签订的自律公约执行机构或行业协会陈述意见，由其调解和裁决；
- 第四，网站服务商在合理的期限内未书面、明确的提出其拒绝修改**Robots**协议的合理理由的，或者搜索引擎服务商认为网站服务商或所有者提出的合理理由不成立的，且搜索引擎服务商认为不立即修改**Robots**协议会严重影响其经营的，可以按照相关法律法规规定采取诸如诉讼、申请行为保全等法律措施予以解决

大众点评诉百度数据爬取案

- 在百度地图中对商家进行搜索时，会在百度地图的页面大量显示部分来自于大众点评网的完整点评信息，百度在使用这些信息时有标注“来自大众点评”的说明并提供链接，可点击该链接跳转到相应的大众点评页面。
- 大众点评认为百度地图的这种行为构成“搭便车”，减少了用户对自己网站的访问，是一种不正当竞争的行为。
- （2016）沪73民终242号（二审）；
- （2015）浦民三（知）初字第528号（上海交通大学 凯原法学院

一审判决理由

- 大众点评网的点评信息是汉涛公司的核心竞争资源之一，能给汉涛公司带来竞争优势，具有商业价值。
- 汉涛公司为运营大众点评网付出了巨额成本。百度公司的使用方式，实质替代大众点评网向用户提供信息，有**明显的“搭便车”、“不劳而获”**的特点。

二审判决理由

- 未经许可使用或利用他人劳动成果的行为，不能当然地认定为构成反不正当竞争法意义上的“搭便车”，否则将在**事实上设定“劳动成果权”**。
- 如果不加节制地允许市场主体任意地使用或利用他人通过巨大投入所获取的信息，将不利于鼓励商业投入、产业创新和诚实经营。
- 因此，需要平衡。综合考虑百度的行为。

广告屏蔽软件案件



- 猎豹浏览器通过技术措施向终端用户提供“广告过滤”功能，当用户打开该功能后访问优酷网站时，合一公司在视频中投放的广告会被过滤。
- 法院最终认定金山公司违反反不正当竞争法。

一审：北京市海淀区人民法院（2013）海民初字第13155号民事判决书

二审：北京市一中级人民法院（2014）一中民终字第3283号民事判决书

引发的相关问题

- 1.如何考虑竞争关系？
- 2.反不正当竞争法一般条款是否适用？
- 3.如何理解反不正当竞争法中公认的商业道德？
- 4.技术中立能否作为抗辩理由？
- 5.消费者福利提升能否作为抗辩理由？
- 6.商业模式保护是否具有正当性？
- 7.广告屏蔽是否影响商业言论自由？

数据专条的适用

- 经营者不得以欺诈、胁迫、避开或者破坏技术管理措施等不正当方式，获取、使用其他经营者合法持有的数据，损害其他经营者的合法权益，扰乱市场竞争秩序。
- 一、合法持有的数据
- 二、获取、使用
- 三、避开或者破坏技术管理措施-宣示权利

淘宝、天猫诉某枫、某陶不正当竞争

- 王某明实际控制的某枫公司、某陶公司，未经淘宝、天猫平台运营方授权，开发了“某商品助手”“某上货助手”等四款有偿“搬家软件”，并向其他电商平台经营者提供服务。
- 软件用户通过上述工具，利用爬虫技术绕开淘宝、天猫平台的验证机制与反爬措施，批量抓取平台内包含商品信息、交易规则、物流适配等在内的海量数据，随后将这些数据通过 **API** 接口“搬运”至其他电商平台，开设无需备货的“无货源店铺”。当消费者在这些“无货源店铺”下单后，软件用户再通过“搬家软件”一键跳转至淘宝、天猫平台的原商品链接完成采购，最终由淘宝、天猫平台及原商家承担发货、售后等履约责任。

平台个人数据获取-“三重授权”原则？

- 微博诉脉脉不正当竞争纠纷
- 三重授权原则

用户授权

平台授权

用户授权

爬取后如果有新的用途，那么要再次告知用户

数据不正当竞争的例外

目前仅有第一条受到了很多判例的支持，其他两条目前并没有受到很多案例的支持

- 一、获取、使用的数据属于公有领域，原告仅是简单搜集，未进行实质性加工
- 二、获取、使用数据不足以造成实质性损害，不会产生实质性的替代效果
- 三、获取、使用数据不会与权利人的正常经营活动相冲突，不实质损害权利人的利益

谢谢
THANKS!

上海交通大学 凯原法学院
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY KOGUAN LAW SCHOOL

地址：中国上海市闵行区东川路800号(200240)
800 Dongchuan Rd., Shanghai 200240, China
Phone: +8621 3420 5612 Fax: 8621 3420 7186 <http://law.sjtu.edu.cn>